

1500381-06.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... um celular e papel com anotações do tráfico.

O réu, em solo policial (fl.04), respondeu que não trabalha formalmente e já possui vários registros criminais por crimes diversos, entre eles tráfico de drogas, roubo, porte de arma, sendo procurado pelo crime de homicídio. Declarou que a aproximadamente duas semanas aceitou voltar a vender drogas, ficando naquele local da 9 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500381-06.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000278

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2050260/2022 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 2050260 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 14/22/301 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Guilherme Andrade dos Santos

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

LUIZ GUILHERME ANDRADE DOS SANTOS, qualificado às fls. 04 e 06/07, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30, nas proximidades de um playground, situado na Viela Nossa Senhora de Fátima, altura do nº 79, bairro do Casa Grande, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 18 embalagens contendo 3,66g da droga cocaína, na forma de crack, e 57 embalagens contendo 185,14g da droga maconha, conforme auto de

apreensão e exibição de fls. 30/31 e laudo de constatação provisória de fls. 36/38, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.57/59), o réu foi notificado e citado (fls.104/105), e apresentou defesa preliminar as fls.120/123, através do d. Advogado constituído. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 04/05/2022 (fl.141).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas tempestivamente, e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína e maus antecedentes do agente, em que pese a sua confissão parcial, que não prepondera sobre a multirreincidência, discordando por isso da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, entendendo deva ser fixado regime prisional fechado mais a perda do numerário apreendido.

Já o d. Advogado reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento de pena por ausência de prova cabal da mesma. E que a pena-base seja fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte, por acolher tese subsidiária da Defesa de se afastar a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei Antidrogas, valendo-me do princípio do in dubio pro reo, como veremos.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.30/31, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls.36/38 e 88/90), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é incontestada não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.02/03), com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, diligenciaram com uma viatura descaracterizada até a Viela Nossa Senhora de Fátima, próximo ao número 79, Casa Grande, Diadema/SP, em um conjunto de prédios, conhecido local de traficância de drogas, onde inicialmente pararam a viatura a distância, com visão para o local onde costuma ficar um buraco no muro, próximo ao play ground, de onde os “vapores”, pessoas responsáveis pela venda das drogas, entregam as drogas para os usuários, de onde puderam visualizar um indivíduo na atividade do tráfico e resolveram aborda-lo. Relatou que efetuaram a abordagem, identificando o indivíduo como sendo LUIZ GUILHERME ANDRADE DOS SANTOS e em busca pessoal foram localizados o valor de R\$ 83,00, um aparelho celular da marca Samsung, dois invólucros de substância esverdeada semelhante a maconha, dois invólucros de pedras assemelhadas a crack, questionado sobre as drogas, assumiu a traficância e indicou um sacola próximo a ele, no chão, e ao verificar o conteúdo da sacola, a mesma continha vários invólucros de substância assemelhada a crack e maconha, embaladas de forma semelhante àquelas encontradas na posse de LUIZ e um

aparelho celular da marca Multilaser, então imediatamente foi exarada voz de prisão ao mesmo pelo crime de tráfico de drogas e junto das substancias foi conduzido até esta unidade e apresentado à autoridade policial.

Sob o crivo do contraditório o policial André Hidalgo confirmou que o local é conhecido como ponto de traficância. Passaram pelo local e notaram que havia um buraco no muro por onde passavam coisas. Havia pessoas do lado de fora, com uma certa movimentação. Adentraram o condomínio, pararam no estacionamento interno e constataram que ele pegava algo no muro e entregava algo em troca. Distraído, o abordaram. Ele estava com drogas e dinheiro nos bolsos e ao lado a sacola com as demais substâncias. Ele confessou a prática de tráfico no local e que era procurado por tentativa de homicídio. Apreenderam uns dez invólucros de crack e maconha com o réu e na sacola havia mais. O dinheiro era trocado, menos de cem reais, e que era da venda de drogas. Disse que era difícil arranjar emprego por ser foragido. Ainda não tinha visto o réu lá antes. Também apreenderam um celular para comunicação direta com os traficantes. O local é dentro de um condomínio, perto de um playground onde ficam crianças brincando. Acredita que não foi solicitado laudo para o local e não fizeram croqui nem tiraram foto.

Igualmente o policial Walter Silveira confirmou que o réu trabalhava nos predinhos já conhecido. Eles usam um espaço vazio entre dois prédios e fazem um buraco no muro para passarem as drogas por ali. Pode ver uma pessoa de cor escura e camisa azul vendendo drogas. Entraram no condomínio, estacionaram na frente do ponto de venda de drogas, cerca de trezentos metros de distância. Assim que ele fez uma venda e se distraiu, conseguiram detê-lo. Com ele havia um pouco de droga e dinheiro e perto dele uma sacola com mais entorpecentes. O réu confessou de imediato o tráfico de drogas e que ganhava até quinhentos reais por dia. Reconhece o réu e não o viu naquela biqueira antes. Tinha movimentação de crianças no local, moradores dos prédios, cerca de trinta metros de distância. As drogas com o réu e as da sacola eram as mesmas, crack e maconha, embaladas da mesma forma. O dinheiro o réu confessou que era das vendas de drogas. Também apreenderam um celular e papel com anotações do tráfico.

O réu, em solo policial (fl.04), respondeu que não trabalha formalmente e já possui vários registros criminais por crimes diversos, entre eles tráfico de drogas, roubo, porte de arma, sendo procurado pelo crime de homicídio. Declarou que a aproximadamente duas semanas aceitou voltar a vender drogas, ficando naquele local da 9 as 15 horas, recebendo para isso parte do valor arrecadado com a venda, o que dá entre R\$ 350,00 e R\$ 500,00 por dia de serviço, dependendo do dia e do volume de venda. Declarou que vende a unidade do invólucro de maconha por R\$ 5,00 e R\$ 10,00, dependendo do tamanho do invólucro e a unidade do invólucro de crack por R\$ 5,00. Declarou que estava no ponto de venda de drogas (biqueira), quando foi abordado por policiais em trajes civis e trazido até esta delegacia.

Em juízo o acusado confessou que estava numa pracinha efetuando o tráfico de drogas. Era seu terceiro dia e recebia cem reais por dia. Não tem playground no local, não tem brinquedo para crianças. Já foi processado por roubo, porte de arma de fogo e tentativa de homicídio que estava procurado. Não estava com anotações do tráfico.

Logo, a confissão judicial (e a extrajudicial) que não é prova única, pois veio corroborada pelos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu confessou o crime tanto informal quando extrajudicialmente, confirmando que estava na biqueira vendendo drogas há alguns dias por não arrumar emprego e já ter várias passagens criminais, não havendo outra prova favorável à sua absolvição.

Não bastasse isso, ressalto o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Com o visto, os policiais sempre afirmaram que o réu, por eles reconhecido, era o indivíduo que estava parado, na biqueira, atendendo os compradores, entregando-lhes as drogas, tanto que em poder dele estavam parte das substâncias entorpecentes e o restante, dos mesmos tipos e embalagens, estavam numa sacola perto de si, que o mesmo indicou, onde também foi apreendido um papel com anotações típicas da contabilidade do tráfico, e dinheiro proveniente deste, tudo sem prova contrária até porque, como já visto, o réu é confesso.

No mais, não há que se falar em situação de pobreza ou desemprego, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Não se pode, ainda, confundir estado de necessidade com estado de precisão. Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Assim como não se pode admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude, sob pena de se legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável. Some-se a isso a ausência de prova da situação de penúria do réu ou impossibilidade de praticar outro tipo de trabalho para seu sustento.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (271 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a reincidência específica do réu (fl. 43) e a apreensão de dinheiro e anotações típicas da traficância (fls. 30/31 e 81) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável no que tange ao crime de tráfico de narcóticos.

Entretanto, no que diz respeito à causa de aumento da pena pela mercancia estar sendo realizada nas proximidades de um playground, o que o réu nega, em que pese os policiais terem dito que a biqueira fica cerca de trinta metros de distância de um parquinho, não há outra prova indicativa de todo o alegado. Como dito pela Defesa, não há fotos nem croqui do local a se ter certeza do que se tratava realmente o local, se um parquinho com brinquedos e com crianças brincando, se uma praça, se um campinho onde moradores pudessem fazer um esporte, se um matagal abandonado, sendo que tudo isso foi indicado na prova oral. Além da distância efetiva entre o ponto de venda de drogas e esse local, bem como a presença de pessoas, crianças brincando para que o tráfico as alcançasse inclusive. Enfim, há dúvida razoável trazida pela Defesa, de modo que a cautela indica ser hipótese de absolvição ante a dúvida que, por lei, milita em favor do agente.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendida (271 no total) o que reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, somado aos maus antecedentes criminais do réu (fl. 43/44 - condenação por porte ilegal de arma que tramitou na 5ª Vara da Barra Funda), estando ele procurado, e nessa condição, praticando delito, a indicar sua má personalidade, fixo em primeira fase, a pena base acrescida de 1/3, ou seja, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos

indicativos da capacidade financeira do condenado.

Opotei por esse percentual ante o princípio da proporcionalidade no que tange à quantidade de narcóticos, pois quanto mais deles, entendo maior deva ser a pena à maior reprovabilidade da conduta, além dos maus antecedentes e má personalidade, pelo fato de ser o réu procurado da Justiça e nessa condição persiste praticando crime.

Na segunda fase, tem-se ser o réu plurirreincidente. Dito isso, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência comprovada a fl. 43 (condenação definitiva por tráfico junto à essa 2ª Vara Criminal local), e agravo a pena em 1/6, pela reincidência atestada a fl. 44, por conta de um roubo cujo processo tramitou na 3ª Vara Criminal de SBC), perfazendo 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão mais 777 dias-multa.

Quanto ao tema, não se mostra recomendável a compensação total da reincidência múltipla com a confissão espontânea, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado (TJSP, 0008486-87.2015.8.26.0635, Relator Grassi Neto; São Paulo; 8ª Câmara de Direito Criminal; 23/03/2017), por isso não se tem como desconsiderar a confissão, que propiciou ao Juízo alcançar a verdade real, e por isso deve militar em favor do acusado, compensando-a com uma das condenações definitivas, restando a outra a aumentar a pena nessa etapa.

Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena, pois embora os policiais tenham alegado que o local da venda de drogas era próximo de um playground, não há uma descrição/levantamento do local, nem um croqui/desenho, nem fotografia, nem outra prova a indicar que ali havia crianças brincando, e que houvesse brinquedos, enfim, pessoas a serem alcançadas pelo tráfico e que o réu as visasse, sendo de inteira relevância que a Acusação realizasse alguma diligência nesse sentido, de modo que não me resta outra alternativa que não me valer da dúvida, que milita em favor do agente, quem inclusive negou haver um parquinho.

Ainda, ausente causa de diminuição da pena. Não reconheço o redutor do §4º, do art. 33 da Lei especial, porque o réu não ostenta bons antecedentes e ainda é reincidente específico a indicar que faz do tráfico seu meio de vida, o que coaduna com a apreensão de dinheiro proveniente da traficância e de anotações típicas de sua contabilidade, indicativos de maior dedicação ao crime.

Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que os 4 anos máximos permitidos) e subjetivo (agente reincidente específico). Ademais: " Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu e a quantidade de pena, mas também a preponderância da natureza da droga crack, não

ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado.

Inclusive: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado.

Ademais: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra LUIZ GUILHERME ANDRADE DOS SANTOS, qualificado às fls. 04 e 06/07, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 07 anos, 09 meses e

10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 777 dias-multa. cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à data dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Absolvo o réu das penas do art. 40, III, da Lei Antidrogas, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele beneficiário da justiça gratuita (fl. 144), reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora, nos termos da Lei estadual nº 11.608 de 2003.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- opere-se a detração penal,
- certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente,
- certifique-se o cálculo da pena de multa,

Decreto a perda de numerário apreendido (fl.81), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA